

從回應式規制到反思式規制*

—— 兼論反思勞動法

李俊增**

目次

壹、前言	肆、小結——回應式規制與反思式規制之比較
貳、回應式規制	伍、兼論反思勞動法
參、反思式規制	一、集體協議與僱傭契約中之自我規制的規制
一、Teubner反思法理論的提出——功能分化社會與反思法作為新的法律規制形式	二、作為反思與降低複雜性之僱傭保障的去規制化
二、Luhmann 及 Bechmann 對於Teubner反思法理論之批判	陸、結論
三、面對Luhmann及Bechmann之批判，反思法理論之進一步發展	

* 筆者一生受吳老師的教誨及提拔至多，無以為報。謹以此文略表對吾師恩德的感念。

〔責任校對：陳怡瑾、許智詠〕。

** 國立高雄大學政治法律學系教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/51119002.pdf>。



壹、前言

福利國家與風險社會導致了規制國家的出現。這表示許多原本自主運作的社會領域紛紛被納入法律規制的範圍，從而出現Gunther Teubner所謂之「法律化」的現象。法律化一方面指法律規制之量與密度增加，另一方面更涉及了法律系統之功能、正當性與結構的改變：功能上法律成為政治系統介入社會、引導社會過程達成目的之工具；法律之正當性取決於其規制社會所獲致之成果；結構上法律特殊化且政策取向化、結果取向化¹。但法律化的發展卻引發1980年代以後有關規制危機之法律社會學的討論；規制性法律被認為深陷危機，或者至少陷於制度失敗的情境。如何理解政治/法律規制所面臨的困境、政治/法律規制所蘊含之社會意象為何、面對規制成效不彰應如何因應等因此成為論爭的焦點。新自由主義者提出去規制化（或法律再形式化）的論述；但另一方面，有論者卻認為法律化的方向基本上並沒有錯。規制性法律的問題在於其執行，所以重點在於設計有效的執行機制。

在有關去規制與強力規制的論戰中，值得注意是有學者提出這兩條路徑中間的第三條路。本文之焦點即在探討第三條路徑中相當具有代表性的兩種規制理論——回應式規制理論與反思式規制理論。這兩種理論各自的奠基理論大不相同。後者奠基於Niklas Luhmann之自我再製系統理論之上，而前者之深層的意識型態則是公民共和主義式之社會民主觀。雖然如此，二者卻有其殊途同歸之處，蓋二者之理論核心均支持某種形式之自我規制：回應式規制理論倡議所謂的強制性自我規制（enforced self-regulation），而反思式

¹ Gunther Teubner, *Juridification – Concepts, Aspects, Limits, Solutions*, in JURIDIFICATION OF SOCIAL SPHERES: A COMPARATIVE ANALYSIS IN THE AREAS OF LABOR, CORPORATE, ANTITRUST AND SOCIAL WELFARE LAW 3, 14-19 (Gunther Teubner ed., 1987).

規制理論則提出經由系統反思而為自我規制之規制的論點。從而探討二者並作比較分析具有重大意義。不過，本文立於自我再製系統理論的觀點，將指出回應式規制理論對於法律的了解有其缺陷。

本文最後將兼論反思勞動法。按Teubner在提出反思式規制理論的同時，曾指出勞動法中有關集體協議的制度，具有「『反思的』潛力」。Ralf Rogowski因此適用反思法概念於勞動法之上，而建構發展所謂的反思勞動法理論。本文認為對於反思勞動法理論之探討，將更能了解反思式規制理論的深度與廣度。

貳、回應式規制

面對去規制之論證，有論者則指出政府介入干預市場以矯正市場失敗的必要性。他們指自由放任政策使得私人掌有不受制衡之壟斷獨占或寡占的權力，從而讓這些公司可以恣意的提高其價格遠高於競爭市場的水平。規制與去規制之論辯自凱恩斯以來已然存在。Ian Ayres與John Braithwaite提出之回應式規制的規制模式即在超越此一規制與去規制之論辯。他們認為好的政策分析不是在自由市場與政府規制間作選擇。規制與去規制間的論辯雙方將論辯型塑成或者自由放任，或者全面規制間二者擇一的政策選擇，但Ayres與Braithwaite卻強調透過創造性的探討私與公規制間的交互作用，可以設計出較佳的方案²。他們即藉由此一探討提出了回應式規制之規制模式。

Ayres與Braithwaite指出回應式規制的獨特性，在於有關什麼觸動規制式回應以及規制性回應會是什麼這兩方面的策略，與其他的

² IAN AYRES & JOHN BRAITHWAITE, RESPONSIVE REGULATION: TRANSCENDING THE DEREGULATION DEBATE 3-4 (1992).

規制模式不同³。「回應性」暗示了對於什麼觸動規制干預有新的觀點，且對於回應應是什麼有新的觀念⁴。就前者而言，回應式規制強調規制應回應產業結構與產業行為，應適應受規制者之動機⁵。就後者而言，回應式規制強調政府規制可以藉由規制功能的授權而促進私的市場治理⁶。進一步來說，Ayres與Braithwaite強調回應式規制觀念的核心是以干預性強之傳統政府規制為後盾，強化並幫助建構較少侵入性與授權形式之市場規制⁷。換言之，面對規制與去規制之論辯僵局，他們所提出的超越方案即是引進逐步提升干預強烈度之階層式、金字塔式的規制策略，在保證必要（亦即授權給私人規制之規制策略失敗）時將採取更為強烈、更具侵入性之傳統政府規制手段下，回應式規制之模式將規制功能授權給私人，而促進私的市場治理⁸。Ayres與Braithwaite表示這一方面將保留自由放任治理的好處，但另一方面又未放棄政府矯正市場失敗的責任⁹。

值得注意的是，Ayres與Braithwaite強調回應式規制並非清楚界定之計劃或一套有關最佳規制方式之處方。反之，最佳的策略是依脈絡、規制文化以及歷史而決定¹⁰。回應式是一種態度，它使得各種規制途徑為之發展，產生了超越規制與去規制之政策對立的不同政策觀念¹¹。但對回應式規制而言，並無最適的、也沒有普遍適用之規制途徑，只有較佳回應歷史某一特定時刻之特殊脈絡的途徑¹²。

³ *Id.* at 4.

⁴ *Id.* at 5.

⁵ *Id.* at 4.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

⁹ *Id.* at 158.

¹⁰ *Id.* at 5.

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

最後，Ayres與Braithwaite指出其所提回應式規制之計劃其深層意識型態面向係抵抗市場觀之民主或自由概念；以共和主義式之社群主義授權的概念（a republican conception of communitarian empowerment）取代自由主義之原子式自由個人的概念¹³。此外，回應式規制之計劃既與新統合主義之模式不同，亦與多元主義有異¹⁴。多元主義的理想是讓各種利益團體自發性地生成，不受干預規制。如下文所述，Ayres與Braithwaite則支持國家與社群授權給本質上較弱的利益，讓這些未組織的群眾能夠組織起來。所以，他們倡議的是進行權力重分配之干預國家¹⁵。此外，Ayres與Braithwaite支持的是共和主義之社會民主觀，而非新統合主義之社會民主觀。後者將利益代表限於生產者團體（包括工會與企業）。前者則不僅授權給生產者團體，亦授權給消費者團體；國家干預授權給無權力者意味的是較少注意已經由市場獲得承認之生產者，而較多注意那些被市場力量排除之群眾，例如在家照顧小孩者，老年人、殘障者等¹⁶。不過，Ayres與Braithwaite指出雖然其所提回應式規制之計劃背後的意識型態為公民共和主義式之社會民主觀，而不同於自由主義、多元主義與新統合主義，但支持其計劃並不需要接受其意識型態立場，因為其所提出之回應式規制乃是一種規制方法，而非規制目的；一種可以協商且富於彈性之方法；一種不同意識型態者均可同意之解決規制衝突的方法¹⁷。

如上所述，回應式規制的核心在於規制授權，並佐以干預性逐步變得更為強烈之傳統政府規制。而被授權規制工作之私的執行者將履行很多的規制功能。Ayres與Braithwaite並具體指出規制工作可以作三大類授權：①授權給公益團體；②授權給受規制之公司本

¹³ *Id.* at 17.

¹⁴ *Id.* at 18.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

身；③授權給公司之競爭者。茲進一步探討之。

(一)、授權給公益團體¹⁸，Ayres與Braithwaite稱之為三方主義(tripartism)¹⁹。三方主義是用來解決一項政策困境：確保規制機關與受規制公司合作演進之好處的政策，卻同時也是鼓勵規制機關被受規制公司擄獲²⁰與貪污腐化演進的政策。按規制機關與受規制公司持續的接觸、遭遇是二者合作演進所必須的。例如當同一檢查員持續的規制處理同一家公司，二者的合作應是更為可能。但二者這種持續性的關係也讓雙方建立信任感，而更易於進行貪污交易，同時其中的風險也降低許多。因此培養合作演進的這種條件也是促進規制機關被擄獲以及貪污腐化的條件²¹。傳統上為解決規制機關被擄獲以及貪污腐化的問題，經常採取限縮裁量權、人員定期輪調等方法。但這些方法卻又妨礙了合作演進²²。為了解決這種困境：一方面確保合作演進的好處，另一方面又能避免規制機關被擄獲以及貪污腐化演進的問題，Ayres與Braithwaite因此提出了共和主義式之三方主義。

三方主義是相關公益團體成為規制者與受規制者間遊戲之第三方玩家的規制策略。作為規制遊戲之第三方玩家，公益團體被授予權力，能夠直接處罰受規制之公司；它也能夠處罰未對不服從規制之公司進行處罰的規制機關²³。為此，公益團體被授權以三種方式

18 必須注意的是，Ayres與Braithwaite指出這裡不應清楚界定什麼是公益以及誰代表公益。因為他們敦促民主政體做的是去依個案情形來辨識能夠最佳爭取（而非代表）特定規制法規所保障之公益的團體。事實上，這些努力爭取規制法規所保障之公益的團體更多時候是私益團體。因此大多數無私益考量之環保團體固然是這裡公益團體，但爭取維護勞工權益之工會也是這裡的公益團體。*Id.* at 58。

19 *Id.* at 54.

20 擄獲(capture)在此係指受規制公司藉遊說而贏得規制機關的心。

21 AYRES & BRAITHWAITE, *supra* note 2, at 55-56.

22 *Id.* at 54, 56.

23 *Id.* at 56.

參與規制過程：①公益團體與其所有成員被准許接近使用所有規制者能夠獲得之資訊；②公益團體在規制機關與受規制公司間之談判桌上被給予一個位子；③公益團體被授予如規制者一般能夠控告、起訴的地位²⁴。

三方主義規制之運作可以舉職業健康安全領域之規制為例。在有工會組織的工作場所，被選舉產生之工會的健康安全代表將如公司之安全幹部一樣，有權陪同規制機關之檢查官員進行檢查。在檢查完畢所舉行之會議以及之後任何會議中，這些工會代表均有權列席旁聽並問問題。他們也能夠收到檢查報告的影本以及檢查官員與公司安全幹部間通聯之任何信息。如果他們看到應告而未告或應採取其他某種執行行動而未採取等情形，他們具有如檢查官員一樣的地位能夠採取相關的執行行動²⁵。

在三方主義規制下，授予公益團體執行機關規制之地位，這些公益團體將能夠關鍵性地影響受規制公司擄獲規制機關的能力，因為被授權之公益團體的存在將使得受規制公司除了擄獲規制機關外，也必須同時擄獲公益團體，如此擄獲才能有效果。被授權之公益團體因此有力地阻止了各種形式之擄獲²⁶。

不過，Ayres與Braithwaite區分不同形式之擄獲，有些係具無效率之效果，有些則具有效率之效果²⁷。他們並強調藉由共和主義形式之三方主義規制策略，將能夠促進規制目標的達成，阻止貪污腐化與無效率擄獲，並朝勵有效率擄獲而強化合作演進²⁸。所謂共和主義式之三方主義涉及建立規制合理性（reasonableness）之三方文化；亦即建立一種規制文化，不合理之規制者與公益團體均會受到

²⁴ *Id.* at 57-58.

²⁵ *Id.* at 59.

²⁶ *Id.* at 71.

²⁷ *Id.* at 69.

²⁸ *Id.* at 6.

社會之譴責非難，規制者與公益團體因此被社會化，以致於對無效率擄獲會採嚴厲立場，而對於合作的公司則採合作立場。在此文化中，規制遊戲的三方玩家且會對他方之需求具同理心，從而共同尋求發現雙贏的方案²⁹。

總之，Ayes與Braithwaite指出藉由共和主義形式之三方主義之規制策略，將能夠培養合作的演進，同時亦阻止了無效率擄獲與貪污腐化之演進。

(二)、第二種授權：授權予受規制公司本身，Ayes與Braithwaite稱為強制性之自我規制(enforced self-regulation)。此一制模式涉及國家與個別公司間之協商，以建立適應於每一家公司之特殊性的規制。每一家公司如果需避免由國家所加諸之更為嚴格也更少適應該公司之特殊性的標準，它即被國家要求要自行提出一己之規制標準。更精確的說，公司被國家要求擬定一套適應於公司本身獨特性之規則。惟此一規則至少必須符合國家立法所定之最低限度的標準。而且規則擬定之後尚須送交規制機關批准，如未符合國家所定最低標準，將無法獲批准，而會被退回公司修正。在此過程中，公益團體亦可參與共同來評判公司所提之規則³⁰。就此而言，受規制公司係作為自我規制之立法者，設計擬定一己之規制規則³¹。

但不僅如此，有關受規制公司亦可被授予執行與司法二項規制功能。換言之，受規制公司尚可作為自我規制之執行者，自我監督規則是否被服從貫徹；而且亦可作為自我規制之法官，公司對於不服從的情形將自行進行懲罰與矯正³²。據此，大部分執行的工作與

²⁹ *Id.* at 92-94.

³⁰ *Id.* at 101, 106-07.

³¹ *Id.* at 103.

³² *Id.*

成本均由公司本身支付，公司被要求建立獨立之檢查團隊；公益團體甚至亦可派代表參加此一團隊。至於政府檢查員的功能則主要限於確保此一公司內部檢查團體的獨立性，並監督它的效率及嚴格性³³。當然，受規制公司是否應授予執行及司法功能，則仍依產業結構與過去歷史而定³⁴。然而值得注意的是，強制性之自我規制的規制模式中，保留政府直接執行的權限（包括偶爾的檢查與懲罰）仍是重要的要素。按一旦受規制公司之管理階層忽略或故意不理會公司內部檢查團隊有關違反自訂規則情事之報告及相關建議，此一事實必須向規制機關揭露。如果被隱匿不報，將被政府控訴。如果違規情事僅被政府單方面查出，同樣會被政府控訴³⁵。

上述強制性之自我規制的模式可以舉美國1977年礦場安全衛生法為例。該法允許礦業主自行提出有關礦坑通風、灰塵控制以及屋頂支撐的計劃，交由規制機關核准。該法設定了核准屋頂支撐計劃時必須遵守之標準。在符合此一標準的前提下，礦業主可以自由設計他們一己獨特之屋頂支撐計劃。礦業公司一旦違反經核准之屋頂支撐計劃將受刑事追訴³⁶。

不過，Ayres與Braithwaite指出強制性自我規制之規制模式並非放諸四海皆可適用。此一規制模式適合之特殊脈絡，係當將規制功能授權予受規制公司，比起傳統上由政府直接進行規制更為便宜與更有效果之時。在這個風險社會的年代，要求政府負起檢查規制每一公司之職業安全衛生、環境保護、產品品質等等，對於政府而言，無疑是龐大的財政負擔。強制性自行我規制之模式下，主要的規制成本將由受規制公司本身吸收支付，對於很多陷於財政赤字之

33 *Id.* at 106.

34 *Id.*

35 *Id.* at 103, 118-19.

36 *Id.* at 117.

泥沼中的國家而言，無疑是更為便宜的³⁷。另一方面，有時自我規制比起由政府直接進行規制也更有效果。例如一些大的製藥產業，其公司之檢查員比起政府之檢查員所受的訓練更為優質，他們很多均擁有博士學位。而且公司的檢查員對公司之產品線也具有為政府檢查員所不及之專業的知識³⁸。

(三)、授權給公司之競爭者，Ayres與Braithwaite稱之為部分產業干預（partial-industry regulation）。這是介於對某產業所有成員全面規制與自由放任政策中間的一條路。Ayres與Braithwaite指出某些情境下，部分產業規制的規制模式會優於上述這二種全面或全無的規制政策。所謂部分產業規制，就其最廣的意義而言，係指政府僅規制某產業中的部分公司，其他公司則不受規制；亦即在此一規制模式下，政府有目的地對產業中之公司作差別對待³⁹。

部分產業規制的規制模式之起點，係認為部分相互競爭公司的存在能夠強烈地影響整個產業之競爭性的行為及表現。其核心洞見是政府藉由維持某產業中部分公司間相互競爭的表現，能夠達成很多的規制目標⁴⁰。因此與否定競爭之效果者不同，部分產業規制的規制模式利用受規制公司來影響市場中其他公司，以促進競爭。但也與全面規制產業不同，錯誤的政府政策並不會對不受規制的公司產生不利的影響，從而緩和了錯誤之政府政策的影響力⁴¹。

部分產業規制之所以可以視為一種規制授權形式，是因為產業中受規制的公司承擔了確保不受規制公司遵從的責任。不受規制公司之所以會遵從是因為競爭迫使他們必須跟進受規制公司的決策⁴²。

37 *Id.* at 103.

38 *Id.* at 104.

39 *Id.* at 133.

40 *Id.* at 134.

41 *Id.* at 134, 142.

42 *Id.*

雖然部分產業規制可以採取很多不同的形式，Ayres 與 Braithwaite 則根據規制對象的不同，區分三種規制干預策略，茲分述如下：

（1）、規制機關僅對產業中主宰性公司，亦即較大型且在價格或其他競爭性變數的設定上居於主導地位之公司進行規制，去限制這些公司反競爭性的行為，而對於較小型、邊陲性的公司則不作規制⁴³。具體而言，此類規制策略可以是對於主宰性公司設定販售其產品之最高價格，從而限制其在未受規制之市場中本來擁有之市場力量。這不但可以降低主宰性公司之價格，也可以降低其競爭者之價格，因此能夠嘉惠消費者。不過，此類規制策略也可以是設定主宰公司產品之最低價格，從而促進市場之競爭性，終而嘉惠消費者⁴⁴。

（2）、第二種部分產業規制之模式是規制機關對於產業中主宰性公司不作規制，而僅干預影響邊陲性公司的行為，以求維持競爭者的存在或創造其他的競爭者，從而結構性的促進該產業自由競爭的表現。就此，政府可以採之手段很多，包括政府可以對小型競爭者提供各式各樣的補助；直接補助新進入市場的公司，或提供優惠利率的貸款以維持既存之邊陲性公司。此外，累進公司稅制亦可提供較小之競爭者競爭的優勢⁴⁵。

（3）、有些產業沒有主宰性公司與邊陲性公司的區別，而僅存在相對類似規模的公司。在這種產業環境中，採取上述（一）或（二）之規制策略均可；亦即可以限制該產業部分公司之反競爭性行為，亦可對新進入市場之公司進行補助。在某些情況下，採結合這兩種策略的途徑亦可。例如政府可以一方面干預以促進新公司進

43 *Id.* at 135-36.

44 *Id.* at 136.

45 *Id.* at 138-39.

入市場，並規制其產品之價格⁴⁶。此外，當產業中之公司規模大致相等時，促使公司競相爭取贏得「錦標賽」之規制策略，是有效的策略。在規制錦標賽中，規制機關係依產業中各公司之相對表現而來對待個別公司⁴⁷。

上述（1）、（2）、（3）這三種規制策略可以個別使用，也可以混合在一起使用以提升產業之競爭環境⁴⁸。最後，Ayres與Braithwaite並指出（1）、（2）與（3）這三種規制策略可以與自由放任以及產業全面性規制這兩種策略共同組成階層式之規制干預的金字塔；此一金字塔由下而上，規制策略之干預性愈來愈強。規制者可以依產業環境競爭性程度等產業現實，以及各種策略之成效而因應採取不同之規制策略⁴⁹。

規制授權給私人的三大類型已如上述，但不可忽略的是Ayres與Braithwaite一再強調的，規制授權必須以侵入性較強之傳統政府規制為後盾，據此形成逐步提升干預強烈度之階層式、金字塔式之規制策略，茲以下圖所示為例：

⁴⁶ *Id.* at 141.

⁴⁷ *Id.* at 141-43.

⁴⁸ *Id.* at 153-54.

⁴⁹ *Id.* at 154-55.

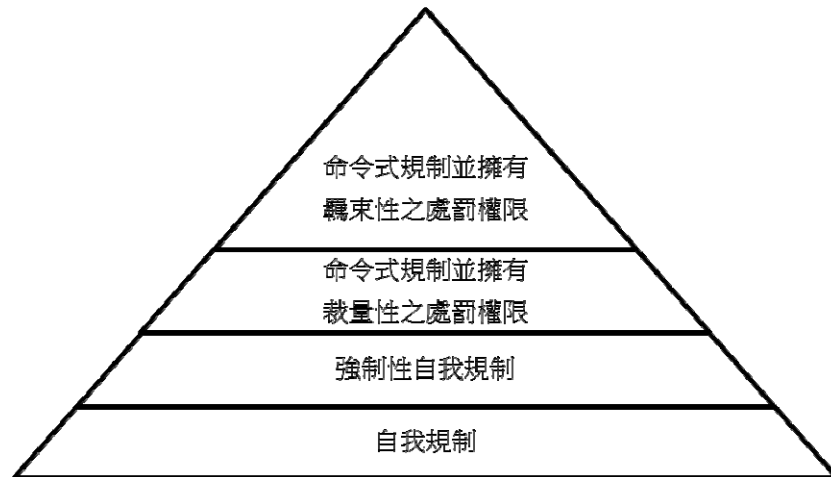


圖1 規制策略之金字塔圖

資料來源：作者自製。

隱含在這種金字塔式之規制策略背後的觀念是沒有嚴懲在背後作後盾，愈不可能促使受規制者自我規制，而且規制者所擁有的棍子愈大，它們使用的機會將會愈少⁵⁰。

最後必須再一次提醒的是，上述三種授權模式並非普遍適用，並非無論時空背景永遠是適當的。反之，授權模式的適當性是脈絡依賴的，例如應取決於產業結構與市場失敗的性質⁵¹。舉例而言，當市場失敗傷害的是與公司有契約關係的消費者，則競爭會迫使不受規制的公司跟進受規制公司受規制之契約的定價。反之，在工業污染的情形，受損害者與違規污染之公司通常並無契約關係，競爭並無法迫使未受規制公司跟進受規制公司的行為。從而藉由部分產業規制之規制模式，可以提升整體產業的競爭性，進而提供消費者較低廉或品質更好的產品選擇。但此一規制模式對於促使整體產業

⁵⁰ *Id.* at 38-41.

⁵¹ *Id.* at 159.

遵從環保標準則無效。規制石油產業中某些公司的廢棄物排放，並不會因此就促使其他公司跟進⁵²。

總之，無論如何，回應式規制之核心在於將規制工作授權給私人，並佐以侵入性更強之傳統政府的規制手段作為後盾。藉此，Ayres與Braithwaite強調能獲致一種規制均衡，一方面保留市場競爭的諸多好處，另一方面又能追求矯正市場失敗之規制目標。他們聲稱所達成的此種均衡超越了規制與去規制政策之對立。

參、反思式規制⁵³

如上述，福利國家與風險社會導致了規制國家的出現，規制國家又造成法律化的現象，從而引發了去規制與規制之論戰。在這些論戰中，1983年Teubner於〈現代法律中之實質與反思要素〉乙文中，提出了反思法（reflexive law）⁵⁴的概念；指出面對功能分化之

⁵² *Id.*

⁵³ 這一節主要摘自筆者〈社會自主性與法律規制——對Teubner反思法理論之檢視〉乙文，並作些微調整修正。這篇文章收錄於筆者《法律、權力與社會》乙書。該書係為升等而出版，市場上並無流通販售，參見李俊增，社會自主性與法律規制——對Teubner反思法理論之檢視，收於：法律、權力與社會，頁99-169（2016年）。

⁵⁴ 值得注意的是reflexive一詞包含反身及反思二種意涵。就前者而言，依系統理論之目的，反身被界定為過程之適用於自身，例如「對於思考之思考」（thinking of thinking）；「對於溝通之溝通」（communicating about communication）。另一方面，在法律之脈絡中，反身則指「關於法律制定之立法」（making laws on law-making）；「對於自我規制之規制」（regulating self-regulation）。據此，在規範的層次，反身法乙詞指的是權能、形式與程序規則，這些規則構成了社會自我規制之過程。就反思此一意涵而言，指的是「內省某些事物」。見Graf-Peter Calliess, *Lex Mercatoria: A Reflexive Law Guide to an Autonomous Legal System*, 2(17) GERMAN L.J. 1, 1 (2001)。Reflexive law固具有這二種意涵，不過，由於本節討論的焦點之一主要係就具有自我再製封閉性質之社會次級系統之反思的意涵及能力界限作深入探討，故reflexive law本文僅譯為反思法。

複雜社會，法律形式之演化，出現了反思法之階段。該文在法律社會學界立刻引起廣泛注意與討論。隨後幾年中，來自經驗主義法律社會學者與Luhmann等系統論者紛紛針對反思法概念，提出批判討論，這些批判討論促使Teubner之反思法理論出現兩次重要的理論釐清與修正⁵⁵。

按Teubner最早在〈現代法律中之實質與反思要素〉乙文中，原企圖結合Philippe Nonet與Philip Selznick之回應法理論、Jürgen Habermas之批判——解放理論，以及Luhmann系統功能論等這些不同理論要素，以建構其反思法理論。惟同年召開之「反思法與規制危機研討會」中，經驗主義法律社會學者針對反思法概念所提出之批判，則促使Teubner在1984年大幅度地轉向，轉變成主要依賴Luhmann之自我指涉（或自我再製）系統理論作為反思法理論之基礎。然而，Teubner此一理論上的努力卻遭遇來自Luhmann與其他系統論者強烈之質疑。此一批判使得Teubner更激進地轉向，其反思法概念幾乎完全蘊含於自我再製之法律系統的理論之下。面對這些批判，Teubner並有意識地建構或解釋釐清其與Luhmann之系統論幾個重要概念的差異。整體而言，Teubner反思法理論之建構，某種程度言，實意味對於Luhmann自我再製理論之重解釋，並工具式地使用它，以論證自我再製環境中法律規制之可能性，以及指出更有效之法律規制方式。

整體而言，本節主要分為三個部分：首先，討論早期Teubner反思法理論之建構，闡明這個時期之反思法概念蘊含以系統反思作為控制手段而為自我規制之控制的意涵。第二部分則是討論

55 有關Teubner反思法理論之探討及批判，可以參考筆者另一篇文章，李俊增，程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯馬斯對韋伯法理論之批判談起，收於：法律、權力與社會，頁1-97（2016年）。這篇文章原刊於李俊增，程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯馬斯對韋伯法理論之批判談起，歐美研究，42卷1期，頁83-165（2012年），後經相當幅度修改，收錄於筆者所出版《法律、權力與社會》乙書。

Luhmann與Gotthard Bechmann對反思法之批判。第三部分則是探討面對Luhmann等系統論者之批判，Teubner所作理論上之修正。在這些理論修正中，Teubner明白建構、釐清其與Luhmann在某些重要概念（尤其是系統反思與結構耦合等）上之不同。其中最核心的理論改變是Teubner坦承法律系統經由反思無法突破雙重封閉性而與環境建立直接接觸，但為了解釋自我再製環境中法律規制之可能性，Teubner另闢蹊徑重解釋結構耦合（structural coupling）概念。此外，Teubner並指出除自我規制之控制以外之其他四種實現反思法概念之具體途徑。

一、Teubner反思法理論的提出——功能分化社會與反思法作為新的法律規制形式

Teubner之反思法概念之提出一方面係奠基在Luhmann之自我再製系統理論，另一方面則是被置於Max Weber有關法律之形式與實質取向之法律演化論的脈絡中。Teubner指出當代社會演化出現了由自我再製系統構成之功能分化社會，為了回應功能分化社會之挑戰，於是有新的法律形式——反思法——的發展。反思法是一種新的法律規制社會工具；它係以系統反思作為控制手段，而為自我規制之規制，是一種間接規制。Teubner認為反思法此種規制形式能夠避免自由主義國家形式法律規制以及福利國家實質法律規制的缺點；換言之，面對功能分化社會，反思法係更有效之規制社會手段。

依自我再製系統理論，Teubner指出當代社會一方面高度功能分化成各個自主之次級系統，另一方面這些自主次級系統並相互依賴且依賴程度日趨增加。這意味社會不再呈現出階層模式；國家不是控制社會之核心，反之，國家只是諸多次級系統之一。再者，這也代表社會更趨複雜；不僅各個自主次級系統呈現高度之個別的複雜性（內部複雜性），由於各次級系統更加相互依賴亦呈現出諸次

級系統間關係之高度複雜性（外部複雜性）。

進一步言之，Teubner指出系統自主性係指系統之自我指涉的與自我再製的組織；按依自我再製理論，社會系統（包括從社會分化出之社會次級系統）係溝通系統，其要素為溝通。而溝通是社會系統之內部運作；且溝通建立在之前的溝通上，以此方式溝通再生產自身。換言之，社會系統之要素的互動是運作上封閉，且反覆地再生產其要素，社會系統因此是自主的。以法律系統為例，法律系統之自我指涉封閉可以在法律裁判與規範性規則的循環關係中看到：裁判指涉規則且規則指涉裁判⁵⁶。

不過，Teubner強調系統自主性並非意味系統即隔絕於其環境；反之，系統仍是對環境開放，只是此一開放性係奠基在系統之運作封閉上。從而系統與環境之關係並非直線式之因果關係或輸入/輸出關係。申言之，自我再製系統由於其自我指涉之循環性，系統之間彼此並無法直接互動。自我指涉封閉系統僅與一己之要素內部地互動。為彌補此一激進之相互不可接近性，系統乃建構自己能與之內部互動之有關外部世界的內部模式⁵⁷。換言之，系統之開放性表現為系統內部地建構一己之環境，而與此一環境建構互動。

在Teubner看來，自我再製之自主性系統的出現對當代社會帶來了重大難題。首先，他認為自我指涉性是危險的結構。蓋自我指涉系統永遠處於自我封閉的危險中；亦即它傾向過度依一己之特定的理性而作選擇性地運作，以致忽略其運作對社會環境造成之負面的外部效果⁵⁸。再者，社會之功能分化誘引高度專化之次級系統競

⁵⁶ See Gunther Teubner, *Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg*, 18 LAW & SOC'Y REV. 291, 291-301 (1984).

⁵⁷ *Id.* at 296-97.

⁵⁸ Gunther Teubner, *After Legal instrumentalism? Strategic Models of Post-Regulatory Law*, in DILEMMAS OF LAW IN THE WELFARE STATE 299, 316 (Gunther Teubner ed., 1986).

相發展一己特定理性以致激進之系統間的衝突不可避免。由於這種系統不同理性間之分裂性的衝突無所不在，社會之整合因此成為一大問題⁵⁹。面對這些系統外部複雜性的難題，Teubner表示對於功能分化社會仍有進行法律規制之必要，而不能任由社會盲目演化。另一方面，Teubner也認為自我再製封閉之系統彼此間雖然相互不可接近，但法律仍然可能發展對社會之規制關係。不過，面對社會次級系統之自我指涉結構，面對系統之內部複雜性，確實意味法律規制必須受到限制；法律必須放棄隱含直接因果關係模式之直接規制此種規制形式⁶⁰。

在這些了解之基礎上，Teubner指出立基於自由主義架構之形式法律之規制形式並未發展任何對抗社會自我指涉封閉之動力的機制，不足以因應系統之外部複雜性。至於實質法律之規制形式則隱含了直線式之目標——手段或因果關係取向。面對規制系統與受規制系統之自我指涉結構的內部動力，實質法律之規制形式因此為之觸礁。申言之，實質法律之規制形式未能維持「規制系統（法律與政治）自我生產之內部互動與受規制系統自我生產之內部互動」三者間並容之關係，或者說未能遵守規制系統與受規制系統之「結構耦合」此一條件，從而不可避免將陷入規制三難之困境：法律（政治）與社會「不協調」、社會「過度法律化」或法律「過度社會化」。換言之，實質法律造成了規制危機，此一危機來自不同社會次級系統內部邏輯之不相並容性⁶¹。

總之，當代功能分化社會中，為能因應系統內部複雜性與外部複雜性之挑戰，一方面為避免（或者至少減低）次級系統對環境造成負面外部效果並防止社會趨向分裂性的分化，因此有規制或控制

⁵⁹ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, 17 LAW & SOC'Y REV. 239, 266-67, 270 (1983).

⁶⁰ Teubner, *supra* note 56, at 298-99.

⁶¹ Teubner, *supra* note 58, at 299, 309-11.

社會之必要，另一方面規制或控制又必須尊重社會自主性。為此，法律系統發展出新的法律規制形式——反思法。值得注意的是，此時Teubner之反思法理論蘊含有以系統反思作為控制手段之意涵⁶²。反思法之意旨，即係經由系統反思而為自我規制之控制，其目標則為獲致「受規制之自主性」。這意味各社會次級系統在反思中學習相互注意、考量彼此，從而調整適應彼此之自我規制。的確，Teubner指出⁶³：

反思意味自我控制之形式，其中局部性系統（partial systems）議題化一己之正身（identity）⁶⁴，並使之調整適應如下事實：在其相關環境中其他局部性系統以相互依賴之關係而為行為，以及它們本身因此必須構成對其他這些局部性系統有用的環境。

然則，反思成為控制的手段；反思作為控制之手段意味個別社會次級系統在發展一己之觀點時，能夠同時反思其社會條件，將環境中其他社會次級系統納入考量之中；系統能夠經由反思一己之社會條件而自我限制，從而與其他系統成為對彼此有用之環境。

當然，進行此種自我規制之控制的關鍵，即是法律發展出反思

⁶² Gotthard Bechmann, *Reflexive Law: A New Theory-paradigm for Legal Science*, in STATE, LAW, AND ECONOMY AS AUTOPOIETIC SYSTEMS: REGULATION AND AUTONOMY IN A NEW PERSPECTIVE 417, 422, 426 (Gunther Teubner & Alberto Febbrajo eds., 1992); Hans-Georg Deggau, *Identity, Reflection and Control in the Legal System*, in STATE, LAW, AND ECONOMY AS AUTOPOIETIC SYSTEMS: REGULATION AND AUTONOMY IN A NEW PERSPECTIVE 451, 468-69 (Gunther Teubner & Alberto Febbrajo eds., 1992).

⁶³ Vgl. "Gunther Teubner/Helmut Willke, Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch Reflexives Recht, Zeitschrift Für Rechtssoziologie 1984, S. 4." cited Deggau, *supra* note 62, at 463.

⁶⁴ Identity一般譯為「同一性」，不過此處identity的意涵與「同一性」並不完全一樣，故譯為「正身」。在此，正身意味系統使自身成為自身之統一性（或整體）之概念（自我概念）。正身乃自我觀察過程之結果。舉例而言，一家公司所設定之目標、其計劃、正當性與價值優先序列等整體即構成一家公司之正身。

理性。法律系統之反思係指法律系統建構有關社會中之法律的內部模式，並使用此一法律之正身以生產法律自我轉變之規範性標準⁶⁵。這進一步意味法律系統建構能夠明白考量其環境中其他社會次級系統之自我再製性質的內部社會實在模式，並自我限制，調整一己之規範性結構以適應之⁶⁶。亦即法律系統在企圖規制其環境時，注意其係自我再製環境中之系統，並考量一己之能力限制，而自我轉變其規範性結構。值得注意的是，Teubner並強調指出法律系統之所以能夠建構注意其環境之自我再製性質的內部社會實在模式，在於法律將法律社會學理論納入，並依特定之法律選擇標準，轉變成為社會實在之法律建構⁶⁷。

Teubner並進一步指出法律經此反思所採用之控制形式為較抽象、間接之控制形式；亦即自我規制之控制形式。更精確地說，由於對社會次級系統之自我規制過程無法從外部控制，因此法律之工作僅限於外部地刺激系統內部之自我規制過程⁶⁸。這又意味法律關於控制社會所扮演之角色限於促進與控制能夠自我反思、具學習能力之社會次級系統的建立⁶⁹。從而法律僅「提供其他社會次級系統內反思過程之結構性前提」⁷⁰，「培養系統性地促進其他社會次級系統內反思結構發展之機制」⁷¹。Teubner並選取Habermas之理論要素，表示只有藉由「社會次級系統之民主化」創造其內部之論辯結構，這些次級系統內之反思才有可能⁷²。這進一步意味了法律之程序化：它「藉形成（社會系統）內部論辯之程序以及（這些系統）與其他社會系統之協調方法，以結構化與再結構化半自主之社會系

65 Teubner, *supra* note 58, at 301.

66 Teubner, *supra* note 56, at 293, 300; Teubner, *supra* note 59, at 280.

67 Teubner, *supra* note 58, at 301; Teubner, *supra* note 59, at 280-81.

68 Teubner, *supra* note 56, at 298.

69 Teubner, *supra* note 58, at 307.

70 Teubner, *supra* note 59, at 275.

71 *Id.* at 275.

72 *Id.*

統」⁷³。更具體而言，法律針對個別之特定次級系統，建立程序規範，規制組織、程序與權能等面向，以決定其未來決策之結構前提，從而促使系統對於最大化其內部理性之企圖所可能產生的外部效果保持敏感性⁷⁴。Teubner並且認為社會次級系統內之反思結構乃是功能分化社會中之主要整合機制，它為社會之去中心化的整合建立了結構前提⁷⁵。

總之，面對功能分化社會所造成系統外部複雜性的難題，Teubner堅持不能任由社會盲目演化，仍必須對社會進行法律規制。再者，面對系統內部複雜性，面對社會次級系統自我再製之自主性，Teubner仍然認為藉諸法律而對之規制是可能的。不過，由於無法對自我再製系統作直線因果關係模式之直接規制，因此有反思法此種規制形式的發展。反思法係藉由系統反思作為控制手段，而為自我規制的控制。亦即法律經由反思而調整其規範結構。法律之工作因此限於外部刺激其他社會次級系統內部之自我規制過程，限於促進能夠自我反思之社會次級系統的建立。從而法律之反思取向，使得法律在進行規制時，能夠避免破壞諸多社會生活範型（pattern）。整體而言，此一了解下的法律，一方面反思並回應諸多不同社會次級系統之理性，另一方面又使用法律符碼將這些理性轉譯為一己之語言。據此，法律一方面因其一己之理性而具有獨特性，但同時又浸於社會持續分化與衝突之過程中。

二、Luhmann及Bechmann對於Teubner反思法理論之批判⁷⁶

然而，面對由自我再製系統構成之功能分化社會，系統反思是否真的能夠作為控制手段呢？對於功能分化社會法律規制是否真的

⁷³ *Id.* at 255.

⁷⁴ *Id.* at 275, 278.

⁷⁵ *Id.* at 255, 273.

⁷⁶ Luhmann及Bechmann以外其他系統論者對反思法理論之批判，見李俊增（註53），頁110-123、145-159。

可能呢？自我再製系統在反思中，是否真的可能注意並考量環境之自我再製性質？凡此，Teubner遭遇了來自Luhmann等的強烈質疑。Luhmann明白地否定在自我再製系統理論所設之限制下，社會次級系統具備Teubner所稱之反思的能力，從而反思法不可能是控制的工具。

的確，Luhmann對於Teubner反思法之批判，即聚焦於系統反思之能力限制的問題上。這是在探討法律設置反思法計劃的問題前，必須釐清之有關法律認知能力之先決問題。如上述，Teubner指出反思之法律理性要求法律系統視自身為自我再製環境中之系統。Luhmann即質疑作為自我再製封閉系統，法律系統實際上能否承擔此一工作？他懷疑地質問：「在什麼範圍內，法律系統之理論工具……能夠注意並考量其環境中之自我再製系統？」⁷⁷。

進一步言之，Luhmann強調法律系統之反思，僅僅是內在於法律之觀察過程。而由於每一觀察均係奠基於區分之上。所以關鍵在於藉由何種區分的協助，系統能夠以系統內部地、自我再製地適用之意義，觀察內部或外部事物？Luhmann因此指出法律系統反思能力限制的問題因此是，如果法系統係以合法/非法之角度而觀察自身及所有其他事物，如果它必須藉此一區分之協助以作出標示指出，那麼對於其環境中次級系統之自我再製性質的洞視將因此受到什麼限制？或者是鑑於法律僅能依合法/非法此一符碼觀察自我之事實，法律自我議題化之限制為何⁷⁸？

針對此一問題，Luhmann指出法律僅僅以其再生產自身的方式，才能夠考量社會（包括法律本身）自我再製地再生產其自身此

⁷⁷ Niklas Luhmann, *Some Problems with Reflexive Law*, in STATE, LAW, AND ECONOMY AS AUTOPOIETIC SYSTEMS: REGULATION AND AUTONOMY IN A NEW PERSPECTIVE 389, 393 (Gunther Teubner & Alberto Febbrajo eds., 1992).

⁷⁸ *Id.* at 393-94.

一事實。這也就是說法律僅能夠在一己合法/非法之二元符碼的狹隘視角內了解其他系統，除此之外，系統不可能了解其他系統。從而法律根本無法看到、不可能了解其環境之自我再製性質。Luhmann並指出藉由反思途徑，法律最多僅能強化一己對其社會條件之自我敏感性；亦即反思這個觀察形式僅僅有助於系統將結構耦合的方向調整到環境中某些特定的系統。系統會使自己愈來愈敏感於（它所建構出來的）環境中這些系統的運作。但這不表示系統比以前更加開放⁷⁹。至於Teubner表示法律系統之所以能夠建構注意其環境之自我再製性質的內部社會實在模式，係借助了社會學知識。針對此，Luhmann亦明白表示社會學知識並無法藉由反思法此一概念，而擴增地、無阻礙地流入法律。反之，重點依然是所有觀點之系統主觀性以及因此不可避免之系統相對性。法律內部模式之獨立性因此係對立於社會科學之內部模式⁸⁰。從而，Teubner所言法律藉助社會學知識能夠注意、考量環境中之其他社會次級系統的論點，並無法成立。Luhmann因此聲稱「反思法只能夠是自我反思之法律」。所謂法律控制、規制所有社會系統之自我再製性質（例如以Teubner所稱自我規制之規制的意義），根本難以想像⁸¹。

Bechmann對上述Luhmann之論點，作了更進一步的闡釋，Bechmann認為如果認真看待自我再製理論此一途徑，視法律為對其他社會系統之規制工具的觀點根本難以成立。首先，他同意Luhmann之論點，認為從自我再製系統之自我指涉以及因此而產生之所有觀點之系統相對性來看，法律不可能是對其他社會次級系統控制的手段。反之，藉由再生產一己之反思性，法律僅僅使自身對一己之社會條件敏感化⁸²。他並引Heinz von Foerster之名言，指出

79 *Id.*; 魯貴顯，現代社會中政治引導是否可能？——一個系統理論的思考，東吳社會學報，10期，頁237-238（2001年）。

80 Luhmann, *supra* note 77, at 397.

81 *Id.* at 397-98.

82 Bechmann, *supra* note 62, at 423.

「系統觀察系統，別無其他」，而Teubner視反思法為對其他社會系統之新的控制形式，將法律干預解釋為建立其他社會系統之反思過程的結構前提條件，已經逾越「系統觀察系統，別無其他」此一界限⁸³。此外，他表示依自我再製理論，法律僅能藉諸法律而改變，並不能藉由其他事物而改變，從而法律只有藉諸指涉自身而是反思法。從而反思法實是法律系統回應法律之「實證性」——即一己之社會偶然性——之自我描述。反思法是法律之理論反思，是對於其他法律理論之失敗的重構分析；它是法律有關社會狀態之解釋，在這當中法律系統發展關於一己之理論，並因此而規制其與一己之環境建構的關係。據上，反思法很難是控制理論或可以影響其他社會次級系統使之反思之控制工具⁸⁴。

法律反思只是內在於法律之觀察過程，因此反思法只能夠是自我反思之法律。反思法不可能是控制的理論或控制的工具。不僅如此，Luhmann指出系統反思能力限制的問題涉及反思法一個更為根本性的問題：「相關系統，尤其是法律系統，如何處理（反思法）所隱含之反思的負擔」。對Luhmann而言，這特別意味著如下之難題：「此一反思使得系統面對了攸關其存在之弔詭⁸⁵」。換言之，反思法隱含意味法律系統必須承認其基本弔詭，從而冒著自我毀滅的風險。申言之，Luhmann指出反思法所蘊含法律系統之反思的能力，意味法律系統必須學習看見它所看不見者；必須學習規制它所無法規制者。這是所有干預系統均必須面對之難題。從而，所有的認知在反思其可能性之條件時，最終將獲致如下的了解：它無法了解它所未了解者。此一反思使得系統面對了弔詭（paradoxicality）。此一弔詭在於看到係因為看不到；規制係因為無法規制⁸⁶。然則，

⁸³ *Id.* at 423-24.

⁸⁴ Bechmann, *supra* note 62, at 431-32.

⁸⁵ Luhmann, *supra* note 77, at 411-12.

⁸⁶ *Id.*

如果反思法意味法律系統面對其基本之弔詭，這無異危及反思法之存在可能性。

三、面對Luhmann及Bechmann之批判，反思法理論之進一步發展

面對Luhmann等之批判，Teubner一方面固仍堅持Luhmann之理論觀點，認為資訊僅能在系統內部生產，社會次級系統僅與一己之社會實在建構互動。他甚至更為清楚地表示法律規制所面對的是雙重封閉性（或雙重循環性）——法律與其他社會次級系統之自我再製封閉⁸⁷。不過，另一方面，Teubner亦指出如果政治使用法律作為控制的工具，那法律系統必須發展與社會實在之連接⁸⁸。然而，如果法律陷於一己之循環，法律如何可能發展此種連接？法律如何可能打破一己之封閉循環，並穿透其他社會次級系統之封閉循環？這是Teubner反思法理論進一步想要、也必須解決的。

為此，Teubner一方面同意Luhmann之觀點，認為系統反思性質上為一種自我觀察，法律系統無法經由反思突破雙重封閉性而建立與環境之直接接觸。雖然如此，與Luhmann不同的是，Teubner仍然堅法律系統經由反思能夠注意並考量社會環境之自我再製性質。他並嘗試在理論上更為清晰地說明這如何可能。另一方面，Teubner則新提出「全社會連接（all-society linkage）」以及立基於此之上的「干擾（interference）」機制二個概念。透過這些理論上的發展，Teubner企圖進一步解釋自我再製環境中法律作為規制之工具如何可能⁸⁹，並具體地指出除自我規制之規制外其他反思法律規制社會

87 GUNTHER TEUBNER, LAW AS AN AUTOPOIETIC SYSTEM 70-71 (1993).

88 *Id.* at 71.

89 值得注意的，在反思法理論之外，Teubner並建構與反思法理論密切相關之法律多元主義的理論。他提出「生產性誤讀」與「連接性制度」二個概念，並在此二概念上解釋說明社會自我生產過程如何轉變為法律生產之源，從而形成法律之多元生產。社會與法律之自我生產過程並因此循環連接一起成為「(超)循

之途徑。茲進一步探討如下。

如上述，Teubner仍循Luhmann之理論，主張系統反思屬系統之自我觀察。與Luhmann一樣，他認為認知系統雖對環境開放，但並無法直接接近其環境，系統只能觀察環境；觀察乃發生於系統本身內部的過程。觀察環境意味系統將其與環境間之區分引入其內部運作，並在這些區分的基礎上作出獨特的標示指出；系統經由內部生產的資訊而建構外部世界之內部模式⁹⁰。不過，另一方面，與Luhmann不同的是，Teubner仍堅持法律系統能夠看到並考量一己以及環境中其他社會次級系統之自我再製性格；他再次表示反思法意味法律系統辨識確認（identify）自身為由諸自我再製系統所構成世界中之自我再製系統，並面對此一結果作出調適⁹¹。然而，僅能自我觀察之法律系統何以仍能「看見」自身與其他社會次級系統之自我再製性質。與之前相同，Teubner再一次指出這是因為法律系統可以藉助社會學之洞見。不過，Teubner作了更清楚之解釋說明。

申言之，他表示所謂社會學（廣義的）洞見，係指在社會學論述中，法律決定並不只被解讀為法律對其他社會次級系統之期待以及服從之要求。反之，法律被各個社會次級系統以第二次解讀的方式被經濟地、政治地或教育地重構；法律決定被轉譯為成本因素、權力位置或教育工具。在此社會學洞見的協助下，法律並經由第三次解讀，以一己之角度重構之前法律決定之結果，再據此調適其未來之決策。Teubner稱此一過程涉及「一系列多重之轉變性重引入（re-entry）」⁹²。經由此一過程，法律系統能夠「理解（verstehen）」

環連接（(ultra-)cyclical linkage）。Teubner不僅指出這種多元生產之「廣義」的法律扮演了社會控制、衝突規制與行為協調等功能，更強調法律多元主義使法律具社會回應性，法律與社會不再只是共演化。這部分詳見李俊增（註53），頁130、141-144。

⁹⁰ TEUBNER, *supra* note 87, at 78-79.

⁹¹ *Id.* at 69.

⁹² Gunther Teubner, *Altera Pars Audiatur: Law in the Collision of Discourses*, in LAW,

其他社會次級系統⁹³；能夠「領會（latch on to）」系統間之「盲目」共演化⁹⁴；能夠「重脈絡化」其他社會次級系統依一己符碼之重構以及依一己計劃之自我引導⁹⁵。或者簡而言之，法律能夠重構其他社會次級系統之理性；能夠了解受規制系統內部如何看它們自己以及如何看待法律規制行為⁹⁶。當然，Teubner堅持建構主義觀點，依然認為法律經濟分析只是法律藉經濟學分析之協助，以法律之角度重構經濟交易，並據此自我調適；法律經濟分析等知識策略均無法跨出法律系統之邊界⁹⁷。換言之，法律此種「理解」、「領會」、「重脈絡化」或「重構」仍只是法律系統一種特殊形式之自我觀察⁹⁸。法律系統並無法經由反思而突破雙重封閉所構成之障礙，建立與環境之直接接觸，從而干預或規制其他社會次級系統。

雖然如此，系統反思卻仍然攸關法律規制之成效。按Teubner強調規制之成功依賴規制系統能夠重脈絡化其規制行為在受規制系統中之重脈絡化；亦即規制系統必須觀察受規制系統之符碼與計劃⁹⁹。更明白地說，法律系統必須（且能夠）了解受規制系統內部如何看待其規制行為，並依此自我改善其規制表現。從而系統反思在反思法作為規制工具中依然佔據關鍵地位。甚至可以說反思法最核心之意涵，即是法律能夠透過了解其他社會次級系統，而可能更為有效地規制它們。更值得注意的是，Teubner在此關於系統反思的解釋，顯然賦予了此一概念具詮釋學性質之感同身受、設身處地

SOCIETY AND ECONOMY 149,169-72 (Richard Rawlings ed., 1997).

93 TEUBNER, *supra* note 87, at 80.

94 *Id.* at 81.

95 John Paterson & Gunther Teubner, *Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis*, 7 SOC. & LEGAL STUD. 451,473-74 (1998).

96 Teubner, *supra* note 92, at 170-72, 176.

97 TEUBNER, *supra* note 90, at 80-81.

98 *Id.* at 80.

99 Paterson & Teubner, *supra* note 95, at 473.

著想的意涵¹⁰⁰。的確，早在1984年Teubner與Willke合寫之文章中，即以「感同身受（empathy）」來表達系統經由反思而產生之系統間的關係¹⁰¹。Teubner此時固然表示系統理論意義下之「理解」仍是一種自我觀察，無法超越觀察循環，但是卻又認為其愈來愈深地進入「詮釋學循環」¹⁰²。此種論點同樣顯示蘊含了感同身受之意涵。

但無論如何，系統反思依然是一種自我觀察；系統無法經由反思而突破雙重封閉性，建立與環境之直接接觸。然則，法律系統規制社會，法律作為規制之工具如何可能呢？對此，如上述，Teubner引入了「全社會連接」以及「干擾」二個概念。不過，在討論這二個概念之前，有必要先對「連接（linkage）」這個概念先作探討。如上述，Teubner仍認為系統反思屬系統對於外部世界之內部重讀、重構或重脈絡化，性質上為一種自我觀察。系統並無法經由反思突破雙重封閉性或雙重選擇性。相對於此，Teubner卻表示「連接」（包含「全社會連接」與「（超）循環連接」），使得功能專化之溝通間相互連接。在此涉及Teubner對於Luhmann理論之批判以及對其結構耦合概念的重解釋。他指出一般系統理論中關於運作封閉的概念，在理論上固然發展得很好，但其結構耦合的概念卻發展不足；它不夠複雜以致不足以應付法與社會之特殊難題¹⁰³。Teubner表示此種結構耦合僅僅導致短暫的結構改變；無論何時當社會溝通在合法/非法之符碼下被觀察，法律誤讀其他論述（discourse）僅僅隨機、任意地發生，如微相關回應（tangential response）可以說即是如此¹⁰⁴。相對於法律與其他社會次級系統這

100 此種意涵之反思概念Teubner在2000年後之理論建構中，仍居於最核心的地位。詳見李俊增（註53），頁132-134註11。

101 Deggau, *supra* note 62, at 469 (citing Teubner & Willke, *supra* note 62, at 14).

102 TEUBNER, *supra* note 87, at 80.

103 Gunther Teubner, *The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism*, 13 CARDOZO L. REV. 1443, 1445, 1447 (1992).

104 *Id.* at 1458.

種僅僅是短暫的結構耦合，Teubner認為法律在與其他系統之關係上遠較結構耦合之一般概念所允許的更為「開放」¹⁰⁵。為了公正地對待此一法律與社會間之關係，Teubner提出了「連接」這個概念。他區分結構耦合與「連接」二個概念，後者意指使得結構耦合得以可能之必要條件。沒有「連接」，結構耦合僅限於單一地、偶然地接觸之極端情形，其中單一事件作為騷亂而影響單一之結構形成。「連接」則「負責結構耦合能夠發展呈現持續性、密切性（intensity）、品質與制度化之不同價值」¹⁰⁶。Teubner並明白指出在適當的情境下，這些「連接」機制能夠產生系統性之規制效果，從而可以為政治——法律規制之目的而使用¹⁰⁷。

相較於Luhmann之結構耦合概念，「連接」概念的提出使得法律在與其他次級系統之關係上，更為開放。為解釋自我再製環境中法律作為規制之工具如何可能，Teubner並進一步討論「全社會連接」以及立基於此之上的「干擾」機制二個概念。

Teubner指出「社會」本身在某種範圍內將各功能專化之溝通相互連接。進一步言之，Teubner依相耦合系統分屬不同之現象領域（例如意識/溝通），或屬於相同現象領域（亦即社會），而區分兩類結構耦合。第二類即社會分化出之第二級自我再製系統（如法律與經濟）的結構耦合¹⁰⁸，Teubner稱之為「干擾」（interference）。其特徵即在於功能次級系統中每一事件均同時永遠是社會整體之溝通，從而以相當特殊之方式相連接於與其相耦合之系統中的事件¹⁰⁹。進一步言之，Teubner強調存在此種干擾的理由有三：（1）

¹⁰⁵ *Id.* at 1447.

¹⁰⁶ Gunther Teubner, *Autopoiesis and Steering: How Politics Profit from the Normative Surplus of Capital*, in AUTOPOIESIS AND CONFIGURATION THEORY: NEW APPROACHES TO SOCIETAL STEERING 127, 133-34 (Roeland J. in't Veld et al. eds., 1991).

¹⁰⁷ Teubner, *supra* note 106, at 128.

¹⁰⁸ *Id.* at 133.

¹⁰⁹ *Id.*

所有社會次級系統均使用相同的基本材料：意義；(2) 它們均在同一要素運作——溝通——之基礎上發展其系統；(3) 各個社會次級系統之專化的溝通形式均永遠同時是一般社會溝通之形式¹¹⁰。換言之，雖然每一社會次級系統之要素並不相同（如法律行為、支付等形式），但本質上仍然是社會溝通，均屬於相同之現象領域：社會；而且要素也是由相同之材料——意義——所構成。社會次級系統並非重新創造其要素、結構等，而只是賦予之新的意義。這些要素、結構與過程仍然是社會溝通。既然各社會次級系統之要素本質上是類似的，系統間之相互干擾即使得系統不只能夠相互觀察且使得系統能夠超越自我觀察而彼此連接，相互地直接接觸或真實地溝通接觸¹¹¹。

從而，法律論述固封閉在一己之自我再生產中並生產一己之實在建構，但它仍然永遠是社會溝通，使用一般社會之實在建構，並藉其特殊之世界建構而影響一般社會溝通。任何法律行為同時是一般社會溝通事件，從而同一溝通事件連接了二個社會論述：法律之專化的、制度化之論述以及一般社會溝通¹¹²。不過，必須注意的是，Teubner強調法律與其他社會次級系統間之干擾並非意味資訊在系統間傳遞交換。反之，資訊仍然是在各個社會次級系統內部重新生產，不同的僅在於資訊係同時地且在同一溝通事件上，於相關系統內部重新生產¹¹³。

藉由系統反思與立基於全社會連接上之干擾機制的結合，Teubner指出經由法律之社會規制是可能的。他表示這是法律經由反思而自我規制以規制社會；這是以極為間接且相當不確定方式而

¹¹⁰ TEUBNER, *supra*, note 87, at 86.

¹¹¹ *Id.* at 86-89.

¹¹² Gunther Teubner, *How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law*, 23 LAW & SOC'Y REV. 727, 745 (1989).

¹¹³ TEUBNER, *supra* note 87, at 87; Teubner, *supra* note 112, at 745.

進行之規制¹¹⁴。Teubner並區分四種間接規制形式，或者說四種反思法之具體途徑。這分別是相互觀察；分岔與吸引子（bifurcation and attractors）（或經由干擾而耦合）；同時化差異減小與經由組織之溝通¹¹⁵。對此之討論，可以更了解系統反思與干擾此二機制在個別反思法之具體途徑中所起之作用。茲進一步分述如下。

1. 相互觀察

此一間接規制形式僅涉及法律系統之反思，而與干擾機制無關。在此，Teubner指出藉助於法律經濟分析之洞見，反思的法律政策能夠「領會」法律系統與其他社會次級系統之「盲目」共演化；能夠「洞見」法律規制僅是自我規制，此一自我規制且以某種模糊方式與受規制系統之自我指涉運作共變化。法律並從此一洞見有所學習、作出調適¹¹⁶。從而採取Teubner稱為「相互觀察」之間接規制形式。具體言之，法律系統藉由掌握領會法律與經濟系統之盲目共變化，從而尋求經由其內部運作而影響此共演化機制；其中最重要者即法律系統藉由審思地增加法律內部變化的可能性（例如增加可能之訴訟種類，納入團體訴訟），而影響法律與其他社會次級系統之共演化過程¹¹⁷。

2. 分岔與吸引子

此一規制形式同時涉及反思與干擾二機制。Teubner指出受規

¹¹⁴ TEUBNER, *supra* note 87, at 65, 97.

¹¹⁵ 在1993年LAW AS AN AUTOPOITIC SYSTEM 乙書中，Teubner僅提出「相互觀察」、「經由干擾而耦合」以及「經由組織之溝通」三種途徑。後來在1998年與Paterson合寫之文章*Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis*中，他所提出者則為「分岔與吸引子」，「同時化差異減小」以及「具拘束力之制度」。這其中「分岔與吸引子」即之前的「經由干擾而耦合」，而「具拘束力之制度」即「經由組織之溝通」。因此整體而言，提出了四種實現反思法概念之具體途徑。

¹¹⁶ TEUBNER, *supra* note 87, at 80-82.

¹¹⁷ *Id.* at 81-83.

制系統在外部干擾之基礎上，能夠獲致新的吸引子狀態（attractor-states）。從而，藉由一般規範或特定之法律行為，法律能嘗試生產此一外部干擾，激擾（irritate）其他社會次級系統，使之從其吸引子狀態朝與立法者目標相容之吸引子狀態移動。換言之，利用此一干擾，將可能「探測出敏感的干預點」，其會觸發可欲的不穩定，使受規制系統移動至接近立法者目標之吸引子狀態¹¹⁸。實踐此種探測的方式之一係藉助「選擇政策（option policy）」¹¹⁹。亦即法律可以發展選擇政策而增加規制性干擾。值得注意的是，Teubner強調選擇政策之發展係奠基在有關受規制系統之知識上。當然，法律對於受規制者之知識係來自法律系統之反思；即來自對法律經濟分析等知識之學習與利用，而重構其他社會次級系統之理性（例如經濟系統成本效益分析之邏輯¹¹⁹）。

總之，反思的法律政策要求發展奠基在有關受規制系統之知識上的選擇政策。舉例而言，主管機關不強行規定銀行之資本適足率，而提供不同途徑供銀行依其成本效益考量選擇。較高層次之途徑要求更精細的風險評估與管理技術，但相對地則提供銀行降低其必須維持之資本額度的機會，從而可以最有效地運用其資產。如此一來，規制者既可促使銀行往風險降低之吸引子狀態移動，又不致傷害銀行最大化有效運用其資產的能力¹²⁰。

3. 同時化差異減小

此一反思模式同樣同時涉及系統反思與干擾二概念。此一模式之特色在於其推衍自Luhmann有關計劃之特殊理解，法律系統之反

118 Teubner Gunther, *Regulatory Law: Chronicle of a Death Foretold*, 1 SOC. & LEGAL STUD. 451, 462-64 (1992); Paterson & Teubner, *supra* note 95, at 475.

119 TEUBNER, *supra* note 90, at 93.

120 John Beattie Paterson, *Reflecting on Reflexive Law*, in LUHMANN ON LAW AND POLITICS: CRITICAL APPRAISALS AND APPLICATIONS 13, 26-27 (Michael King & Chris Thornhill eds., 2006).

思因此及於受規制系統之計劃。按Luhmann指出依自我再製理論，系統引導僅僅只能是系統之自我引導，而此一自我引導又應理解為差異減小計劃，計劃本身乃是系統尋求降低目前方向（即問題）與所欲方向（即解決）間之差異的手段¹²¹。同樣的，Teubner亦表示藉由法律對社會之規制的企圖僅能是多重之自我引導過程，僅能是多重之循環封閉、差異減小的計劃。在此理解之基礎上，Teubner指出一般而言，在特定之社會領域中，會有數個自我規制過程同時在進行。而當數個差異同時被最小化，它們彼此將部分地相互增強，部分地相互破壞。針對此，法律提供之規制性干擾同樣只是在減小一己之差異。不過，由於法律之差異最小化計劃所構成之規制信息會被其他次級系統重構、重脈絡化。這些規制信息可以造成受規制系統內之某一自我引導計劃（或差異最小化計劃）需要更多成本，或對另一計劃提供誘因。換言之，此一干擾將改變受規制系統內各個自我引導計劃間之競爭態勢¹²²。

據上，「同時化差異減小」此一反思模式，仍然涉及了系統之相互觀察。只是進行觀察之系統其注意的焦點不只在受觀察系統所劃之區分（即符碼）。而且也在受觀察系統所建構之差異以及減小此差異之企圖（即計劃）¹²³。當然此一觀察並無法逾越進行觀察系統之符碼所設下的界限。但重要的是，此項觀察，在考量雙重偶然性以及受觀察系統之自我引導計劃下，有較佳機會獲致更適切之關於環境的圖像¹²⁴。

4. 經由組織之溝通

如上述，早期Teubner借用Habermas之理論指出落實系統之反

121 Niklas Luhmann, *Limits of Steering*, 14(1) THEORY, CULTURE & SOC'S 41, 46-52 (1997).

122 Paterson & Teubner, *supra* note 95, at 476.

123 Paterson, *supra* note 120, at 29-30.

124 *Id.*

思，須將系統之內部程序民主化。當時並未就此一論點在自我再製理論的脈絡下作探討。如今Teubner則提出經由組織之溝通的模式。此一模式同樣涉及系統反思與干擾二概念。不過，如上述，Teubner強調的不只是法律系統之反思，且是經由法律而促進受規制系統之反思。此外，尤其重要的是，Teubner提出能跨越功能系統邊界之正式組織的概念。Teubner指出社會主要次級系統（如政治、法律、經濟等）既無法集體行動，因此為了溝通，它們需要具集體行動能力之正式組織。在正式組織中，不同之溝通系統「平行地相互傳輸」。按由於正式組織具拘束力，有能力拘束政治、經濟或法律等，它能夠迫使不同之自發的、未受控制之平行的差異流（即溝通系統）於某段時間內匯集一起，使之必須彼此相互並容；亦即使不同系統之支配團體所持關於外部世界之建構相互調適，為了其他系統之運作而對一己系統之潛力自我限制。以此經由正式組織而溝通的方式，規制者即能夠獲致系統性效果¹²⁵。

與早期之觀點相同，Teubner強調針對此一調適過程，反思之立法政策限於提供組織內或組織間之組織、程序、權能等程序性條件¹²⁶。而且他也認為法律系統此種程序性規制涉及之反思或對於相關情境之重脈絡化，不必知道什麼組織內之動態，不需法律經濟分析或組織理論等知識之協助¹²⁷。

最後，Teubner指出經由組織之溝通亦係奠基在干擾機制上。按如功能系統與一般社會溝通間之干擾機制一般，正式組織其組織決策之形式同樣也使用溝通作為要素，因此如果組織決策經由同一行為而與法律溝通（或經濟溝通）恰巧一致，則組織即可與法律（或經濟）耦合¹²⁸。

¹²⁵ TEUBNER, *supra* note 87, at 95-97; Paterson & Teubner, *supra* note 95, at 477.

¹²⁶ TEUBNER, *supra* note 87, at 96-97.

¹²⁷ Paterson & Teubner, *supra* note 95, at 477.

¹²⁸ TEUBNER, *supra* note 87, at 96.

藉由系統反思以及立基於全社會連接上之干擾二機制之結合，Teubner進一步發展上述四種實現反思法概念之間接規制形式。不過，整體而言，反思法對於規制之了解最重要的貢獻依然是強調法律應聚焦於自我規制之規制¹²⁹。而自我規制之規制也正是第五節所述反思勞動法之核心特徵。

肆、小結——回應式規制與反思式規制之比較

回應式規制與反思式規制二個理論已如上述，茲就二者之異同比較如下，並突顯反思式規制之優點：

（一）、無論回應式規制理論或反思式規制理論均在尋求脫離強力政府規制以及因此所造成之法律化的困境，但同時又反對完全去規制化，而同意社會規制之必要性，不過二者之理由並不相同。反思式規制從自我再製系統理論出發，強調規制之必要性來自功能分化社會中，社會諸次級系統間之關係存在高度複雜性（外部複雜性）。按自我再製之自主性系統傾向過度依一己特定之理性而作選擇性地運作，以致忽略其運作對社會環境造成的負面外部效果，而且也會導致激進之系統間的衝突。面對此外部複雜性的難題，功能分化社會因此仍有進行法律規制之必要，而不能任由社會盲目演化。

回應式規制理論則僅從務實的角度出發，強調面對今日規制之流的年代，提出回應式規制之創新方案，架構橋樑跨越去規制與贊成規制二大議論間之鴻溝的重要性。按Ayres與Braithwaite指出社群、市場、國家與社團秩序這些制度在某個範圍內係相互構成且相互限制的；它們每一個制度在挑戰及構成另一個制度之權力上均是

129 RALF ROGOWSKI, REFLEXIVE LABOUR LAW IN THE WORLD SOCIETY 39 (2013).

重要的。一方面，社群德性，尤其是信任，使得有效的市場成為可能。而國家也藉由契約法、反托拉斯法構成市場；沒有具相當權威之國家，先進資本主義根本不可能。再者，市場產生之財富使得規制成為可能這種聲稱也有一定的道理。同樣為真的是，社團（如律師公會、會計師公會等）之自我規制也構成了市場；沒有這些社團之自我規制，市場將崩潰以致於失序。但國家也能夠在構成社團秩序上扮演一定角色，如上述，基於規制考量而由國家授權公益團體將能強化或催生這些團體。另一方面，這些制度權力每一個也會受到另一個挑戰，而顯得相當脆弱的。例如國家之規制權力會受到企業去規制化之主張的挑戰。而企業也會受到工會、環保團體等的挑戰。國家同樣會受到社群譴責規制失敗的挑戰。回應式理論認為這些正意味吾人今日並非如左派所認為的是處在去規制的年代，反之，吾人處於規制之流的年代，其中規制、去規制與再規制的轉移正同時發生。從而提出回應式規制以架構橋樑跨越去規制與贊成規制二大議論間之鴻溝，促使已落伍的此二大議論面對規制之流的事實正是時候¹³⁰。

（二）、無論回應式規制理論或反思式規制理論都強調法律應回應社會之必要性。但回應式規制理論在對法律的理解上曝露了其缺點。按反思式規制理論指出了法律在回應社會需求時，由於法律以及其他社會次級系統之自我再製性格，有其限制。但回應式規制理論則並未見及社會高度功能分化成各個自主次級系統所造成之社會複雜性問題，而有所回應。因此回應式規制理論固然正確地強調自我規制之核心角色。但當它要求強制性自我規制之規制策略時，它對法律實要求太多而仍然是一種命令—控制式之規制，從而可能陷入上述Teubner所謂規制三難之困境中。反之，反思式規制理論主張面對功能分化社會法律能夠回應前，法律必須先自我規制而成為

130 AYRES & BRAITHWAITE, *supra* note 2, at 7, 13-15.

反思；法律之自我規制乃是對於其它社會次級系統之自我規制的規制之前提¹³¹。

當然，回應式制理論與反思式規制理論對於社會需求的了解也大相逕庭。後者認為法律所要回應之社會需求係自我再製之社會系統所帶來的難題。前者對社會需求的了解則不是那麼宏觀，而僅強調法律規制應回產業結構與產業行為以及應適應受規制者之動機等。

（三）、無論回應式規制理論或反思式規制理論均主張民主化。惟後者雖強調「社會次級系統之民主化」，但卻同時指出次級系統之民主化的主要功能「既不在增加個人的參與，也不在中立化權力結構」，而是在次級系統之內部反思¹³²；換言之，在反思式規制理論中民主本身並不是重要價值，民主化係為了促使次級系統對於其最大化內部理性之企圖的外部效果保持敏感性¹³³。相對於此，回應式規制理論則不僅明白指出它支持的是公民共和主義式之社會民主觀，並且強調其視共和主義對參與式民主的強調本身即是一具價值之目的¹³⁴。

（四）、無論回應式規制理論或反思式規制理論均支持自我規制之控制形式，但二者之理由則不盡相同。後者之理由係功能分化社會，面對系統之內部複雜性，面對社會次級系統自我再製之自主性，已無法藉諸法律作直線因果關係模式之直接規制，否則將陷入規制三難之困境。因此法律之工作僅限於外部地刺激其他社會次級系內部之自我規制過程。至於回應式制理論，固然也強調自我規制可以適應每一家公司之特殊性¹³⁵，但它更強調的是在顧及規制之必

131 See ROGOWSKI, *supra* note 129, at 142.

132 Teubner, *supra* note 59, at 273.

133 *Id.* at 278.

134 AYRES & BRAITHWAITE, *supra* note 2, at 18, 162.

135 *Id.* at 110.

要性的同時，能促進私的市場治理，而保留自由放任治理之好處。此外，它也從務實的角度，指出自我規制比起政府直接規制更為便宜，而且因為公司檢查人員對自己公司之產品線具有政府檢查員所不及之專業知識，所以規制會更有效果。

伍、兼論反思勞動法

Teubner面對強力規制與去規制之論戰，另闢蹊徑提出了反思式規制理論。同樣的，當今勞動法即面對保守之新自由主義勞動經濟學的攻擊，其聲稱應廢除勞動法而回到僅受私法法規範規制之市場秩序。面對此一攻擊批判，Rogowski提出了勞動法的改革作為回應。Teubner在建構其反思法理論之初，即曾指出勞動法中有關集協議的制度具有「『反思的』潛力」¹³⁶。以此為線索，Rogowski，適用反思法概念於勞動法之上，建構發展了反思勞動法理論。他指出勞動法改革的適當方式，係使之成為反思。他強調反思勞動法乃新類型勞動法，一方面它了解傳統勞動法之限制及排他的效果，另一方面它將新自由主義之去規制了解為一種特殊的規制形式且必須伴隨新的規制或再規制，並因此提出了再規制策略。他表示此一再規制策略能夠經由對這個領域之反思的後設治理（meta-governance）而克服傳統勞動法之問題¹³⁷。本文認為探討Rogowski之反思勞動法理論，將更能了解反思式規制理論的深度與廣度。茲討論如下。

反思勞動法既是理論性概念，也是描述性概念。作為理論性概念，它適用Teubner之反思法概念以及Luhmann與Teubner的自我再製之法律系統理論於勞動法之上；反思法概念聲稱是一符應現代社

¹³⁶ Teubner, *supra* note 59, at 276.

¹³⁷ ROGOWSKI, *supra* note 129, at vi.

會中勞動法之複雜性的新勞動法理論。作為描述性概念，它解釋並重構了在與福利國家之規制困境的關係上，勞動法之趨勢。反思勞動法描述勞動法發展的一個階段，在此階段勞動法了解其在對其他社會系統的規制上，具有系統性的限制；也在其自我規制的能力上發現了力量之源¹³⁸。

反思勞動法理論依功能分化概念來解釋現代法律系統之演化與勞動法領域之發展。據此，勞動法是法律系統內分化的產物，其特徵在於與——獨特的社會系統——勞資關係系統（*industrial relations system*）——有特殊的連結。蓋勞動法作為法律系統之次級系統，在演化之始，大部分即在回應法律對於其新的、促進性角色的認知，而這是法律為了對於勞資關係與僱傭關係產生影響所必須採取的角色¹³⁹。

更重要的是，反思勞動法理論對於法律與勞資關係之性質及二者間之關係，並提供了新的理解。勞資關係與法律並非被視為（集體的）行為系統，而是被視為（集體的）溝通系統。法律與勞資關係各自之系統獨特的（*system-specific*）溝通之自我指涉形成了自我再生產或自我再製之基礎。在此基礎上，二者各自發展成為社會中之自主的系統。依自我再製與反思理論，系統固仍是對環境開放，但此一開放係奠基在系統之運作封閉上；系統與環境之關係並非交換關係，反之，系統乃是與一己對於環境之內部建構互動¹⁴⁰。

138 Ralf Rogowski, *Industrial Relations, Labour Conflict Resolution and Reflexive Labour Law*, in *REFLEXIVE LABOUR LAW: STUDIES IN INDUSTRIAL RELATIONS AND EMPLOYMENT REGULATION* 53, 53 (Ralf Rogowski & Ton Wilthagen eds., 1994) [hereinafter Rogowski, *Labour Law*]; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 39.

139 Ralf Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law: Its Theoretical Background and Possible Applications*, in *LAW'S NEW BOUNDARIES: THE CONSEQUENCES OF LEGAL AUTOPOIESIS* 179, 181-82 (Jiří Přibáň & David Nelken eds., 2001) [hereinafter Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*]; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 39.

140 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 182;

上述將勞資關係與法律二社會系統概念化為運作上封閉之溝通系統之後，才有可能了解不同溝通系統如何以不同種類之規制運作。也才能夠進一步注意到外部規制形式與自我制過程間之重要關係。而儘管勞動法構成法律系統之一部分且因此由法律溝通構成，集體協議（collective agreements）與集體協商（collective bargain）則屬於勞資關係之自我規制結構，最終由勞資關係溝通所構成¹⁴¹。

在上述了解下，Rogowski進一步使用反思法之基本觀念，將之適用在有關現代勞動法之核心面向的討論上。這包括二個部分¹⁴²。（一）、藉由集體協議與僱傭契約之自我規制加諸勞動法之挑戰；（二）、作為反思與降低複雜性之僱傭保障的去規制化。

一、集體協議與僱傭契約中之自我規制的規制

（一）集體協議之自我規制的規制

對於勞資關係之規制自始即是勞動法之主要領域。事實上，勞動法對於勞資關係的承認乃是勞動法作為另一規制領域而發展之主要理由。而法律為了對勞資關係系統之規制需要作適當的回應，法律有必要了解勞資關係系統之性質¹⁴³。在德國，法律學界的Hugo Sinzheimer即已分析集體協議特殊性質為集體行為者規制一己事物之工具。在英國1906年之貿易爭議法（Trade Dispute Act）中，立法者亦已承認勞資關係作為自我規制系統之特殊性格與能力¹⁴⁴。

上述中，無論德國或英國，法律系統均承認為了公正地對待集

ROGOWSKI, *supra* note 129, at 40.

¹⁴¹ Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 182, ROGOWSKI, *supra* note 129, at 40.

¹⁴² 除了這二個部分，尚包括勞動衝突解決之反思要素。由於這部分涉及更廣更深，所以只能另文討論。有興趣者可以參見Rogowski, *Labour Law*, *supra* note 138, at 53-93。

¹⁴³ ROGOWSKI, *supra* note 129, at 41.

¹⁴⁴ *Id.* at 41-42.

體協商之自主性，新的法律工具是必要的。集體勞動法自始即面臨發展支持而非傷害此一勞資關係自我規制機制之規制方式的必要性。事實上，勞動法自始即從事規制新的社會功能系統¹⁴⁵。

的確，在西方現代社會中勞資關係即是已充分發展之功能系統¹⁴⁶。勞資關係中之集體行為者間的溝通構成了勞資關係之基本要素，其核心為集體協商之自我再生產系統。自我再製之勞資關係為自主之集體協商中集體溝通的自我指涉，建立了特殊之制度結構與程序。此一結構與程序為新形式之集體溝通與集體行為建立了一社會領域，此一社會領域是勞資關係系統獨立於經濟、政治與法律系統之基礎¹⁴⁷。

在評估法律系統對勞資關係系統之規制時，重要的是分析此二個系統各自尋求自主性所加諸彼此相互的限制。法律系統係依據其法律觀點中之勞資關係而介入干預，而勞資關係系統則根據一已有關與法律系統之經驗的認知而回應法律系統。這兩個系統或多或少均僅僅為其各自有關外部世界之內部模式所引導。從而經由系統干預之成功的規制大部分係依賴規制系統與受規制系統內部相互承認彼此之需要¹⁴⁸。

¹⁴⁵ *Id.* at 42.

¹⁴⁶ 自我再製之系統理論對於勞資關係作為社會系統之特徵，提供了五個可能性：勞資關係作為①一組互動系統；②作為一網路系統；③作為一社會或抗爭運動；④作為一衝突系統；⑤作為一免疫系統；⑥作為功能分化之社會次級系統。*Id.* at 63-75。而勞資關係作為充分發展之功能系統滿足了Luhmann所論功能系統充分發展必須符合的四個條件：①社會分化之形式與範圍已到達了一個水平，能夠使自主之勞資關係系統不受其他功能系統宰制而發展；②勞資關係系統有關其要素之運作，係以封閉與開放特殊結合的方式而運作；③勞資關係系統係以代表系統之獨有功能的二元符碼（集體地可協商或不可協商）而運作；④勞資關係系統藉由其規制勞動事務的能力，以及安排與其他功能系統統合主義式交換關係以促進一己之自主性的能力，而在社會上獲致相對的重要性。*Id.* at 75-76。

¹⁴⁷ *Id.* at 42.

¹⁴⁸ Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 184; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 42.

進一步言之，對於勞資關係法律規制的種類係依賴法律對於勞資關係認知的種類。法律系統本身作為自我再製系統，在採取非法律之世界觀上，是受限制的。因此，一般而言，法律僅僅視勞資關係為規制對象。但如果勞動法及其制度承認勞資關係系統之自我再製性質，勞動法即從事反思規制¹⁴⁹。

反思法概念主張現代法律的主要問題來自於未反思其他社會系統自我再生產之需要，而採取加諸這些自我再製之社會系統實質標準之傳統規制形式。法律之角色在現代複雜社會中已從權威性之控制工具，轉而成為相互承認自我規制之促進性工具。這已導致法律思想焦點的改變，從規制轉變為治理¹⁵⁰。

勞資關係中自我規制的主要形式，即是以獲致集體協議為目標之集體協商。經由集體協商勞資關係系統履行其社會功能，為集體行為者各方間之和平互動提供了管道。集體協議是勞資關係藉以規制經濟及其他社會生活之重要面向的工具¹⁵¹。

按集體協議有二項基本社會功能。集體協議是勞資間之和平協議，且集體協議也是僱傭期限與條件、工作分配以及工作穩定性等的來源。勞動法因此將集體協議區分成二個部分：集體行為者雙方之具拘束力的契約，以及集體協議之規範性規則制定的功能。如上述，法律對於集體協商的規制必須是促進性的，才能有效果，但這預設了勞動法承認勞資關係這些社會功能。這在法律系統之不同層次均可達成，包括憲法承認集體協商之自主性¹⁵²。

149 *Id.*

150 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 185; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 42-43.

151 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 185; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 43.

152 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 185; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 43.

但是，實際上，勞動法對於集體協商可能是促進性，也有可能是破壞性的。後者可以舉1970年代早期與1980年代英國之勞動法的運用為例。當時英國政府強行規定未經勞資關係雙方同意的法律標準，結果全國性及地區性之集體協商實際上被徹底摧毀。在這些勞動法措施背後的，不只是對於工會的敵視，而且是根本上即質疑勞資關係系統之必要性的激進新古典經濟政策¹⁵³。

不過，集體勞動法，一般而言，藉由提供集體協商能夠順利進行之架構，而自我了解為勞資關係之支持性角色。這對於處理勞資關係之法律面向的規制機關，尤其是如此。勞動法院即了解一己規制能力之限制，而區分由司法處理之衝突類型，與保留給勞資關係之集體協商的自我規制處理之衝突類型。前者是僱傭關係破裂後而衍生之衝突，後者則是僱傭關係持續中發生之衝突。司法被認為較適合社會關係終止後之衝突，其目標在於平衡衝突雙方之利益¹⁵⁴。

法律變成反思之關鍵步驟，即在於法律了解到其他社會系統之自我規制過程，最好是法律藉由規制其自身來促進之。現代法律系統區分衝突解決功能與對其他系統之規制。從自我再製觀點來看，法律系統在衝突解決上運用法律工具（包括規範、程序與法律原理），能夠停留在其自我規制之邊界內。而對於其他社會系統之規制則要求更為複雜地將社會需要轉譯為法律促進。對於其他社會系統之規制之所以不同，即是因為對法律系統而言並無內在的指導方針來阻止規制被作破壞性使用的可能性，且法律系統此時必須依賴外部資源來評估其產生的影響¹⁵⁵。

153 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 185; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 43.

154 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 185-86; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 43-44.

155 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 186; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 44.

(二) 僱傭契約之自我規制的規制

勞動法之自我規制的規制並不限於法律與勞資關係間之關係，此一觀念亦能夠適用在僱傭契約之規制上。按任何對於契約之法律規制必須考慮自我規制。如果契約法要能有效率，它必須了解其自身為規制自我規制的機制。契約法當它設法藉由授與契約雙方自主性來確保合作，以及設法以契約雙方一己之語言來表達他們對於此一關係之期待時，契約法即變成反思的¹⁵⁶。

但是，僱傭契約是一特殊的規制對象。一般而言，僱傭契約之特徵在於契約雙方之權力分配並不均衡。因此勞動法在此的功能，即必須藉由堅持公平與無歧視標準的遵守，來抵銷此一權力的不均衡¹⁵⁷。但是，對於這些標準的遵從不是依賴懲罰的施加，而是依賴授與契約雙方自主性並促進其彼此信任。進一步言，確保對於僱傭標準的遵從一方面需要控制，因此對於工作場所的檢查有其角色。但另一方面這些控制不能取代僱主與勞工遵守標準的意願¹⁵⁸。從而，舉例而言，勞動法可以鼓勵僱主授與勞工界定及履行工作之裁量權，以交換勞工更大的忠誠及專業性¹⁵⁹。或者勞動法亦可以為個別勞工建立以權利形式執行勞動標準的誘因。當然，反思勞動法承認執行權利的問題，為解決此一問題，須採程序途徑，在工作場所建立僱主與勞工協商的機制¹⁶⁰。

事實上，僱傭法之獨特的特徵即在於其歷史上依賴程序規制，尤其是促進集體協商作為自我規制的工具¹⁶¹。不過，應注意的是，

¹⁵⁶ HUGH COLLINS, *REGULATING CONTRACTS* 64 (1999).

¹⁵⁷ See HUGH COLLINS, *JUSTICE IN DISMISSAL: THE LAW OF TERMINATION IN EMPLOYMENT* (1992).

¹⁵⁸ Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 187; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 45.

¹⁵⁹ COLLINS, *supra* note 157, at 22.

¹⁶⁰ HUGH COLLINS, *EMPLOYMENT LAW* 29-30 (2d ed. 2010).

¹⁶¹ *Id.* at 31.

除了集體協商，僱傭法尚存在與之同樣重要的其他形式之自我規制。這包括工作委員會¹⁶²或勞工代表參與公司之共同決定計劃或參與安全衛生委員會¹⁶³。

二、作為反思與降低複雜性之僱傭保障的去規制化

現代社會中所有功能系統一個常在的問題是內部複雜性。不只系統之結構傾向於擴增，那些利用作自我指涉關係或其他循環關係之系統——獨特的溝通，其數量也不斷擴增。就法律系統而言，不僅判例，它的結構成份包括法律規範、程序規則與法律原理亦均傾向以不同方向發展。除此之外，法律系統亦分化為各種自主之法律次級系統，如勞動法¹⁶⁴。

勞動法此一法律次級系統亦如法律系統一般，面臨法律複雜性之相同問題。保障勞工之法規及其他規範不斷增加，司法以及其他救濟程序不斷改進，支持裁判作成但同時又使裁判作成更增複雜之勞動法原理同樣一直在成長¹⁶⁵。

法律複雜性的增加通常伴隨法律規制的增加。因此法律複雜性不只對於法律系統是一大問題，對於那些受勞動法規制之其他社會系統亦然。這些問題已經導致一項指控：法律規制造成了社會規制之法律化¹⁶⁶。

內部複雜性與外部複雜性構成了不可迴避的問題，現代法律系統必須作適當回應。如果注意處理勞動法複雜性之政策，即會發現

¹⁶² ROGOWSKI, *supra* note 129, at 47.

¹⁶³ *Id.*

¹⁶⁴ Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 191; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 47.

¹⁶⁵ *Id.*

¹⁶⁶ Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 191; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 47; *see also* Teubner, *supra* note 1.

一項顯著的策略：勞動法，尤其是僱傭保障，的去規制化¹⁶⁷。

然而，去規制政策的背後隱含了不同的計劃或意識型態。例如一項去規制勞動法之保守計劃，即通常專注於法律規制之經濟效果。它著重於「去負擔化之企業」與公司之「需要」。此一觀點之去規制化奠基在新古典之經濟假設，認為去除法律並降低僱傭保障的水平將能自動改善公司之業績表現而對於勞動市場有積極正面的影響¹⁶⁸。

一項較為平衡的途徑則在設計去規制策略時，不只追求經濟目標，也追求更廣的社會目標。這些社會經濟目標通常與設法降低失業之勞動市場政策直接相關。這種社會去規制策略企圖對勞資關係與僱傭關係採取更為平衡的觀點。它同時考量勞資雙方立場，試圖在僱主降低保障水平之需求，與勞工尋找並確保安全工作之利益間，達成平衡¹⁶⁹。

在某些去規制政策下則存在文化的面向。這些策略涉及對於工作之一般態度的轉變、人口之發展以及女性在求職上的利益。這所伴隨之去規制的類型則傾向聚焦於僱傭形式的彈性化以及降低限制非典型僱傭之障礙等。女性在勞動市場參與率的增加，要求自由化並支持兼職工作，除去相關之法律障礙或其他障礙（如社會安全）¹⁷⁰。

最後，對於反思勞動法而言，去規制化的動機則在於降低法律複雜性。去規制的政策如果是法律系統之自我規制，則可以稱為反

167 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 191-92; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 48.

168 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 192; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 48.

169 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 192; ROGOWSKI, *supra* note 129, at 48.

170 *Id.*

思去規制。反思去規制平衡法律降低複雜性之內部需求以及與法律之社會環境相關之更廣的去規制目標¹⁷¹。

不僅如此，從系統理論觀點觀之，去規制政策必須處理來自不同系統邏輯相衝突而產生的高度複雜性。勞動市場之去規制至少必須處理五個不同系統指涉。去規制政策乃係政治系統藉由法律系統的改變而影響經濟過程的企圖。而這些改變則對勞資關係系統與家庭產生直接影響。反思去規制因此須在所有這些系統中發現去改變既有處理問題方式的意願；且反思去規制依賴這些系統回應其需求的意願。反思去規制必須與各系統中各個系統——獨特之降低複雜性的方式相連結，且彼此並容。換言之，反思去規制必須了解自身為一自我規制之規制的形式¹⁷²。

再者，必須注意的是，便是當去規制被使用作為達成公共目標之供選擇的規制策略時，去規制變成了反思。去規制因此成為常規的事務，且幾乎總是伴隨著再規制策略；它涉及的主要是關於應使用何種規制策略來達成某種公共目標之事實求是的選擇問題¹⁷³。的確，就反思勞動法的觀點，反思去規制是對於規制之控制性的評估；反思去規制係藉由結合除去規制與再規制之策略而降低複雜性，並支持進一步地將立法權限授權，以藉由自我規制來改善規制之有效性¹⁷⁴。

總之，反思去規制係對於法律系統之內部複雜性的回應；也是對於去規制所涉及之不同系統邏輯衝突而生之複雜性的回應。因此它從事的是複雜性的降低。而且就反思法觀點，去規制幾乎總是導致新的規制。無論如何，去規制本身即是一特殊形式之規制¹⁷⁵。

171 *Id.*

172 ROGOWSKI, *supra* note 129, at 143-44, 170.

173 *Id.* at 142.

174 *Id.* at 140.

175 Rogowski, *The Concept of Reflexive Labour Law*, *supra* note 139, at 193;

陸、結論

本文探討、比較了回應式規制與反思式規制理論。對於Teubner之反思式規制理論，並且討論了系統論者Luhmann等對之所作的批判以及Teubner之回應與理論修正。整體而言，無論回應式理論或反思式規制理論均在尋求脫離強力政府規制以及因此所造成之法律化的困境，但二者同時又反對完全去規制化，而同意社會規制之必要性。為此，這兩種理論的理論核心均指出應採某種形式之自我規制：回應式規制理論倡議所謂的強制性自我規制，而反思式規制理論則提出經由系統反思而為自我規制之規制。不過，回應式規制理論並未見及社會高度功能分化成各個自次級系統所帶來之社會複雜性問題，而有所回應。因此回應式規制理論固然正確地強調自我規制之核心角色，但它所要求之強制性自我規制的規制策略，對法律實要求太多而依然是一種命令——控制式之規制，從而可能陷入Teubner所謂規制三難之困境中。反之，反思式自我規制理論立基於Luhmann之自我再制系統理論上，強調法律在回應高度功能分化社會之需求時，經由系統反思能夠看到並考量一己以及環境中其他社會次級系統之自我再製性格，並面對此而為自我規制之規制；法律之工作因此僅限於外部地刺激其他社會次級系統內部之自我規制過程，從而可以避免規制三難之困境。

本文最後並探討適用反思法概念於勞動法之上而建構出之反思勞動法理論。反思勞動法理論指出勞動法經由反思能夠看到並考量勞資關係系統之自我再製性質，承認勞資關係作為自我規制系統之特殊性格與能力，公正地對待集體協商之自主性；換言之，勞動法係從事反思規制。從而，勞動法之角色在現代複雜社會中從權威性之控制工具，轉而成為相互承認自我規制之促進性工具；促進勞資

ROGOWSKI, *supra* note 129, at 48.

關係自我規制機制之規制方式。同樣的，面對僱傭契約之自我規制的規制，勞動法之功能也限於促進公平與無歧視標準的遵守，以抵銷契約雙方勞資權力的不均衡。最後，對於反思勞動法而言，去規制的政策乃是法律系統之自我規制，可以稱為反思去規制。反思去規制係對法律系統之內部複雜性的回應，也是對於去規制所涉及之不同系統邏輯衝突而生之複雜性的回應。而且就反思法觀點，反思去規制係藉由結合除去規制與再規制之策略而降低複雜性。

參考文獻

1. 中文部分

- 李俊增（2012），程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯馬斯對韋伯法理論之批判談起，歐美研究，42卷1期，頁83-165。
- （2016），程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯斯對韋伯法理論之批判談起，收於：法律、權力與社會，頁1-97，臺北：新學林。
- （2016），社會自主性與法律規制——對Teubner反思法理論之檢視，收於：法律、權力與社會，頁99-169，臺北：新學林。
- 魯貴顯（2001），現代社會中政治引導是否可能？——一個系統理論的思考，東吳社會學報，10期，頁225-249。

2. 外文部分

- Ayres, Ian, and John Braithwaite. 1992. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York, NY: Oxford University Press.
- Bechmann, Gotthard. 1992. Reflexive Law: A New Theory-paradigm for Legal Science. Pp.417-433 in *State, Law, and Economy as Autopoietic Systems: Regulation and Autonomy in a New Perspective*, edited by Gunther Teubner and Alberto Febbrajo. Milan: Giuffrè.
- Calliess, Galf-Peter. 2001. Lex Mercatoria: A Reflexive Law Guide to an Autonomous Legal System. *German Law Journal* 2(17):1-3.
- Collins, Hugh. 1992. *Justice in Dismissal: The Law of Termination in Employment*. Oxford: Oxford University Press.

- . 1999. *Regulating Contracts*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2010. *Employment Law*. 2d ed. New York, NY: Oxford University Press.
- Deggau, Hans-Georg. 1992. Identity, Reflection and Control in the Legal System. Pp. 451-481 in *State, Law, and Economy as Autopoietic Systems: Regulation and Autonomy in a New Perspective*, edited by Gunther Teubner and Alberto Febbrajo. Milan: Giuffrè.
- Luhmann, Niklas. 1992. Some Problems with Reflexive Law. Pp. 389-415 in *State, Law, and Economy as Autopoietic Systems: Regulation and Autonomy in a New Perspective*, edited by Gunther Teubner and Alberto Febbrajo. Milan: Giuffrè.
- . 1997. Limits of Steering. *Theory, Culture and Society* 14(1):41-57.
- Paterson, John Beattie. 2006. Reflecting on Reflexive Law. Pp. 13-35 in *Luhmann on Law and Politics: Critical Appraisals and Applications*, edited by Michael King and Chris Thornhill. Oxford: Hart Publishing.
- Paterson, John, and Gunther Teubner. 1998. Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis. *Social & Legal Studies* 7:451-486.
- Rogowski, Ralf. 1994. Industrial Relations, Labour Conflict Resolution and Reflexive Labour Law. Pp. 53-93 in *Reflexive Labour Law: Studies in Industrial Relations and Employment Regulation*, edited by Ralf Rogowski and Ton Wilthagen. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- . 2001. The Concept of Reflexive Labour Law: Its Theoretical Background and Possible Applications. Pp.179-196 in *Law's New Boundaries: The Consequences of Legal Autopoiesis*, edited by Jiří Příbán and David Nelken. Aldershot: Ashgate.

- . 2013. *Reflexive Labour Law in the World Society*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Teubner, Gunther. 1983. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. *Law & Society Review* 17:239-285.
- . 1984. Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg. *Law & Society Review* 18:291-301.
- . 1986. After Legal Instrumentalism? Strategic Models of Post-Regulatory Law. Pp. 299-325 in *Dilemmas of Law in the Welfare State*, edited by Gunther Teubner. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
- . 1987. Juridification – Concepts, Aspects, Limits, Solutions. Pp. 3-48 in *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law*, edited by Gunther Teubner. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
- . 1989. How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law. *Law & Society Review* 23:727-757.
- . 1991. Autopoiesis and Steering: How Politics Profit from the Normative Surplus of Capital. Pp. 127-142 in *Autopoiesis and Configuration Theory: New Approaches to Societal Steering*, edited by Roeland J. in't Veld, Catrien J. A. M. Termeer, Linze Schaap, and Mark J. W. van Twist. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- . 1992. Regulatory Law: Chronicle of a Death Foretold. *Social & Legal Studies* 1:451-475.
- . 1992. The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism. *Cardozo Law Review* 13:1443-1462.
- . 1993. *Law as an Autopoietic System*. Oxford: Blackwell.
- . 1997. Altera Pars Audiatur: Law in the Collision of Discourses. Pp. 149-176 in *Law, Society and Economy*, edited by Richard Rawlings. Oxford: Clarendon Press.

Teubner, Gunther/Willke, Helmut (1984), Kontext und Autonomie:
Gesellschaftliche Selbststeuerung durch Reflexives Recht,
Zeitschrift für Rechtssoziologie 5, S. 4-35.